

社科法學的傳統與挑戰*

侯 猛**

摘 要

中國的社科法學初步形成具有集聚效應的研究成果和研究群體。這意味著它既不是傳統意義上的法社會學，也並非只是用一個新概念來指代跨學科法律研究。它的特別之處在於，建立了一套多邊跨界對話機制，來整合不同進路的跨學科法律研究。在持續的對話過程中，不同進路的社科法學者形成了經驗研究、實用主義、後果導向、語境化分析等基本共識。但從整體上來看，社科法學必須通過與法教義學的競爭，才能強化其知識傳統的認同。

關鍵詞：社科法學、經驗研究、實用主義、後果導向、語境化分析。

* 本文曾刊登於法商研究，2014年第5期，頁74-80。

責任校對：呂佳霖、徐寧。

** 北京大學法學院副教授。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/82114171.pdf>。



目 次

- | | |
|------------------|------------------|
| 壹、為什麼簡稱「社科法學」？ | 二、通過經驗研究形成中國法律理論 |
| 貳、從「法社會學」到「社科法學」 | 三、解決法教義學不能解決的問題 |
| 參、有沒有統一的「社科法學」？ | 四、職業訓練、智識挑戰與政治判斷 |
| 肆、「社科法學」的功用 | |
| 一、填補法學和其他社會科學的空隙 | |

社科法學大體上是指研究者運用社會科學的方法來分析法律問題。這與以規範文本為研究中心的法解釋學，及其新興衍生品——法教義學有顯著區別。近年來，留德回國或深受德國法傳統影響的學者越來越多，而且主要集中在刑法、民法，以及憲法領域。法教義學知識體系不僅貫徹於教學之中，而且研究亦有興盛之勢¹。

在中國法學的知識競爭格局中，社科法學者多少感受到了危機。這種危機感並非來自於法教義學對社科法學的排斥或誤讀。恰恰相反，法教義學學者，特別是來自部門法的法教義學學者，對社科法學採取相當克制或友善的態度：「教義學的主張無意排斥其他

1 「法教義學」語詞在中國大陸的流行，與陳愛娥翻譯拉倫茨《法學方法論》一書的影響也直接相關。陳愛娥早先將Rechtsdogmatik翻譯成法教義學。參見Karl Larenz著，陳愛娥譯，《法學方法論》導讀——代譯序，收於：許顯明編，法學方法論，頁2-18（2003年）。但在臺灣法學界更常使用「法釋義學」。晚近的研究，如陳興良，刑法教義學方法論，法學研究，2005年第2期，頁38-56（2005年）；焦寶乾，法教義學的觀念及其演變，法商研究，2006年第4期，頁88-93（2006年）；許德風，論法教義學與價值判斷——以民法方法為重點，中外法學，2008年第2期，頁165-190（2008年）；白斌，論法教義學：源流、特徵及其功能，環球法律評論，2010年第3期，頁5-17（2010年）。

的法學研究進路」²，「教義學若要充分發展，必須借鑒社會科學的研究成果」³。這種危機感更多的體現在，相較於注重邏輯、體系建構的法教義學，社科法學大多集中於個案或具體問題，研究進路多樣。這看起來不僅顯得知識雜糅，同時也意味著難以形成知識的整體優勢與法教義學抗衡。

面對危機和挑戰，除了更高品質的知識產出之外，社科法學還必須與法教義學競爭。通過認識對方來檢視自己，形成學術自覺，強化知識傳統的認同。

壹、為什麼簡稱「社科法學」？

首先需要解釋的是名稱問題。社科法學最早是蘇力在2001年劃分中國法學格局時所概括的⁴。但之後在相當長一段時間裡，社科法學並沒有被經常使用。主要原因有二：一是他當時用社科法學所指代的那些領域，相互隔膜，交集較少。這既包括他自己為代表的法律社會學經驗研究，還包括梁治平為代表的法律文化研究，季衛東為代表的程式法治研究，以及橫跨社科法學和法解釋學的部門法學者的研究，例如，陳興良的刑法哲學研究、王利明的司法研究。二是當時的社科法學研究剛剛起步，還沒有形成一定規模的研究群體，整體上還不成氣候。如今十多年過去，社科法學這個詞慢慢開始被學界所熟悉，首先是現在已經有規模集中的研究群體在使用和認同。這就是所謂「約定」「俗成」。因此，從這個意義上來說，不能使用像社科法學這樣的語詞，取決於使用者的多少，而不是語

2 張翔，憲法教義學初階，中外法學，2013年第5期，頁916-936（2013年）。

3 許德風，法教義學的應用，中外法學，2013年第5期，頁937-973（2013年）。

4 參見蘇力，也許正在發生——中國當代法學發展的一個概覽，比較法研究，2001年第3期，頁1-9（2001年）。

詞本身含義的邏輯程度。

但指代運用社會科學方法來研究法律的概念，並不只是「社科法學」一個。從過去十多年的發展來看，中文還使用過「法律的交叉學科研究」、「法律的社會科學研究」、「法律和社會科學」、「法律社會科學」，等等。甚至，在中文世界中，後面這些概念使用的外延更廣，除了法學，還包括社會學、經濟學、人類學和其他社會科學，更具有跨學科研究和對話的意味。相較而言，「社科法學」的使用範圍較窄，甚至讓人誤以為是法學的某個分支學科。既然如此，為何還要堅持使用「社科法學」？

其實，社科法學的英文名稱是Social Sciences of Law。中文直譯「法律的社會科學」或「法律的社會科學研究」，只是簡稱「社科法學」而已。之所以簡稱，主要是基於兩點理由：

第一，社科法學特別指向的是，那些在法學院進行社會科學研究的學者，以及一部分受到過法學專業訓練，在外院系從事法律研究的社科學者。從而，與在其他院所進行法律研究但未受過法學專業訓練的社科學者，相對有所區分。區分的意義就在於，主要在法學院，社科法學者已經形成了學術體制之外的「無形學院」。很多學術活動已經持續開展，例如，同人集刊《法律和社會科學》在2006年創辦，並已進入CSSCI法學來源集刊；「法律和社會科學」年會、討論會和研習營也相繼舉辦⁵。2013年底，具有學術共同體意義的「社科法學連線」成立，旨在整合各種活動。這意味著，來自不同知識背景的法律社會學者、法律經濟學者、法律人類學者，

5 2005年在北京大學法學院舉辦了「法律的社會科學研究」研討會，這是社科法學第一次標誌性會議。2009年由林端、梁治平兩位老師領導，舉辦了「法律的中國經驗：法律、文化與社會」研討會，集中了年輕一代的社科法學者，社科法學群體隱然形成。2013年在雲南大學法學院、2014年在西南政法大學、2015年在北京大學法學院先後組織了3次社科法學研習營，從各校學生中遴選，邀請十多位學者集中授課。

以及其他跨領域社科法學者的跨界對話格局已經形成⁶。

第二，社科法學名稱儘管不夠嚴謹，但方便交流。在中國法學格局中，除了社科法學，還有法解釋學或法教義學、政法法學。不論是批評還是對話，都是四個字對四個字。例如，社科法學與法教義學的對話。但如果稱為法律和社會科學和法教義學的對話，就相當彆扭，也不容易理解。從知識交流的簡約功能來說，使用社科法學這個詞更具有行動力⁷，更容易與其他法學傳統對話。從這個意義上來說，沒有法教義學，就沒有社科法學。社科法學概念的使用也是相對於法教義學的，通過對比，發現自身的比較優勢和不足。當然，名稱的使用都有特定的語境。如果越來越多的人認為將「社科法學」改稱為「經驗法學」，也未嘗不可。甚至，如果未來自然科學對法學的影響更為巨大⁸，將「社科法學」改稱為「科學法學」同樣不無可能。

貳、從「法社會學」到「社科法學」

對於法教義學的學者來說，相對於法教義學的概念應該是法社會學，而不是社科法學⁹。畢竟，法社會學與法教義學可以在知識體系中加以區分，例如，盧曼（Niklas Luhmann）分別使用社會系

6 參見侯猛，社科法學的跨界格局與實證前景，法學，2013年第4期，頁30-35（2013年）。

7 類似的，維特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）有個著名的例子，「給我一把掃帚拿來」與「給我一把掃帚柄和裝在柄上的掃帚頭拿來」，儘管前者從文字表述上更為含糊，但就促成完成行動而言更為清楚。參見Ludwig Wittgenstein著，李步樓譯，哲學研究，頁44（2000年）。

8 參見李學堯、王淩峰，法律與科學的關係：尋求一種開放的法學立場，中國社會科學報，2012年11月14日A07版。

9 例如，德國法學者湯瑪斯·萊塞爾（Thomas Raiser）所著《法社會學基本問題》，專章討論「論法社會學與法教義學的關係」。參見Thomas Raiser著，王亞飛譯，法社會學基本問題，頁108-126（2014年）。

統與法律系統兩個獨立的系統，來指代法社會學和法教義學的適用空間¹⁰。而且，從法學的知識譜系上來看，法社會學是西方法學三大流派之一。法社會學與法哲學（特別是自然法哲學）、分析法學（法律實證主義）在知識功能上有明顯分野。例如，分析法學研究法律規範的構成和解釋，即「法律是什麼」的問題。而法社會學研究法律規範的實際運行過程，即「法律實際上是什麼」的問題。這樣，兩者在研究物件上相互區隔，基本上「井水不犯河水」，各自有發揮空間。

既然如此，為何我們不接續傳統使用法社會學，而是使用社科法學？這主要與中國社科法學過去30年的發展變化相關。從1980年代開始，由沈宗靈提倡的法社會學研究開始興起。但1990年代以後，法社會學研究開始引入宏大理論範式，例如，國家與社會理論、功能主義理論、程式正義理論、權力技術和現代治理術等，而且引入法律經濟學、法律人類學和後現代主義等各種分析工具¹¹。而2000年代以後，更為重視具體問題的跨學科經驗研究。這意味著，研究已經不再是法社會學那樣以研究範圍或物件為界，而是注重用不同研究進路來分析問題。不僅如此，法社會學研究的發展變化，也對傳統規範法學提出挑戰，從而法學是不是一門社會科學就成為了一個問題¹²。在這樣的背景下，法社會學研究轉向社科法學研究就成為可能。

社科法學與法社會學相比，雖然都直面社會生活中的問題，但在知識上更強調開放性。這就與法教義學所強調的法學自主性有根

10 Niklas Luhmann著，鄭伊倩譯，社會的法律，頁1以下（2009年）。

11 參見強世功，中國法律社會學的困境與出路，文化縱橫，2013年第5期，頁114-120（2013年）；劉思達，中國法律社會學的歷史與反思，法律和社會科學，2010年第2期，頁25-37（2010年）。

12 較早對中國法學缺乏社會科學研究的批評，參見鄭戈，法學是一門社會科學嗎？——試論「法律科學」的屬性及其研究方法，北大法律評論，1998年第1輯，頁13-42（1998年）。

本差別。這種知識的開放性，體現在不會固守法律研究的方法，而是注重社會學、經濟學、人類學、心理學，包括社會生物學、認知科學在內的多學科方法。但需要說明的是，社科法學所強調的知識開放性，只是反對法學自主性和知識封閉性的特徵，並不反對法學本身。實際上，從事社科法學的研究者，就是在法學院從事社會科學研究。他們與法教義學分享基本的法律概念和邏輯，並且將法律規範文本當作討論問題的前提或背景。社科法學仍可以稱得上是法學的一種知識傳統。社科法學能夠得以繁榮發展，也是提升法學在整個知識體制中的競爭力。

在中國語境下討論法教義學與社科法學的對話時，需要注意兩個方面的問題：第一，需要注意背後的兩大法學傳統的差異。法教義學深受德國法學傳統的影響。法教義學談及的與法社會學的比較，他們所理解的法社會學，其實更多的是德國的知識背景，例如韋伯（Max Weber）的法社會學理論。而國內社科法學研究總體上深受美國經驗的法社會學和法經濟學研究的影響。例如，法社會學研究包括法與行為科學、批判法學和法律與發展運動，代表人物包括塞爾茲尼克（Philip Selznick）、布萊克（Donald Black）、麥考利（Stewart Macaulay）、楚貝克（David Trubek）。當然，法社會學研究在美國比較邊緣，但在中國方興未艾¹³。第二，也是基於上述理由，既不能從德國意義上的法社會學理論來理解社科法學，也不能拿美國的社科法學研究作為批評的靶子，而是需要在瞭解現有中國經驗研究的基礎上進行對話。

國內社科法學的經驗研究有哪些？一般說來，標誌性作品是蘇力的《法治及其本土資源》和《送法下鄉》。這也是傳統法社會學

13 參見賀欣，轉型中國背景下的法律與社會科學研究，北大法律評論，2006年第1輯，頁21-36（2006年）；蘇力，好的研究和實證研究，法學，2013年第4期，頁16-20（2013年）。

向現代社科法學轉向的標誌，或許構成了庫恩（Thomas S. Kuhn）所說的範式的轉換。因為構成範式大致上具有兩個基本特徵：第一，科學經典的成就空前地吸引一批堅定的擁護者，使他們脫離科學活動的其他競爭模式。第二，這些成就又足以無限制地為重新組成的一批實踐者留下有待解決的種種問題¹⁴。以這樣的標準來衡量，蘇力的確帶動了整個法學界的研究風氣，吸引了一批後學從事社科法學研究。例如，他開啟了司法制度和個案經驗研究的傳統。在國內，賀欣、侯猛、艾佳慧、唐應茂、汪慶華、劉忠從事的司法經驗研究，桑本謙、王啟梁、陳柏峰、尤陳俊從事的個案經驗研究，都是在他的研究基礎上加以拓展乃至批判。在法律職業、法律與發展領域也有不少經驗研究，前者如劉思達、李國慶，後者如程金華、冉井富。晚近的變化是在法律與認知科學領域，例如，成凡、李學堯。當然，這些學者即使在同一領域，研究進路和風格差異仍然很大，有時觀點也完全對立。例如，賀欣對蘇力的批評¹⁵。但這正是一種「和而不同」的態度。

參、有沒有統一的「社科法學」？

儘管如此，社科法學往往遭受知識碎片化的批評。相比之下，法教義學具有結構清晰、邏輯嚴密自治的知識體系，大有一統法學的氣勢。那麼，社科法學是不是也要追求一個統一的知識體系？實際上，社科法學本身並不追求概念化和體系化，而是注重法律外部的研究視角，強調研究進路（approach）。這些研究進路圍繞著具體的法律問題而展開，是問題導向，而不是法條導向的。

¹⁴ 參見 Thomas S. Kuhn 著，金吾倫、胡新和譯，*科學革命的結構*，頁 8（2013 年）。

¹⁵ See Xin He, *Black Hole of Responsibility: The Adjudication Committee's Role in a Chinese Court*, 46 LAW & SOC'Y REV. 681, 681-712 (2012).

儘管不存在一個統一的、體系化的社科法學，但不同進路的研究者，仍然形成了相對固定的學術共同體。這本身就說明了大家一定是在分享著共同的知識理念。無形學院的形成，讓不同進路的研究者得以進行跨界對話，形成基本共識。而且，社科法學者通過與法教義學者對話，也能夠發現自己的比較優勢，有助於強化基本共識。這些在對話過程中凝聚形成的社科法學的基本共識，主要包括以下幾個方面：

第一，重視法條，但是實用主義的。社科法學與法教義學一樣，都是以法律文本為基礎。但與法教義學尊崇法條和法秩序不同，社科法學關心的是法條的生活世界。正如科斯（Ronald H. Coase）主張研究真實世界的經濟學那樣，社科法學關心的是真實世界的法律問題。社科法學通過分析法條在社會生活中的作用，進而提出立法和政策建議。所以，社科法學同樣重視法條，圍繞法條來展開工作，但絕不會奉其為圭臬，而是採取實用主義的態度。

社科法學與法教義學相比，可能更接近科學。這是因為社科法學採取懷疑主義的態度，對一切可能存在問題的法律條文保持警惕。而法教義學則不同，它首先要對法條採取相信甚至迷信的態度，盡可能通過解釋來維持法體系和法秩序的穩定。這就如李忠夏所言，「在中國社會轉型的大背景下，社科法學與法教義學之間的最大分歧，並非是如何解釋實證法規範的方法問題，而是如何對待實證法的問題。¹⁶」有意思的是，如果與外院系進行法律研究的社科學者相比，社科法學反而又是法律中心主義的。因為前者更為重視秩序、制度和社會規範，而不僅僅是法律。例如，趙旭東的法律人類學研究和張五常的法律經濟學研究¹⁷。

¹⁶ 參見李忠夏，基本權利教義學中的價值判斷——基於社科法學與法教義學的視角，「社科法學與法教義學的對話」學術研討會，中南財經大學法學院、法學研究、法律和社會科學、社科法學主辦（2014年5月31日、6月1日）。

¹⁷ 參見趙旭東，法律與文化：法律人類學研究與中國經驗，頁1以下（2011年）；

第二，首先從後果出發，而不是從法條出發。從後果出發，不僅僅指社科法學研究的是法律的實際後果。更重要的含義是，要從後果出發，逆向分析、解釋、評判法律條文和法律問題。這明顯與法教義學針鋒相對。特別是在重大、轟動、疑難案件中，法官一定是要先考慮後果。這個後果並不只是對於案件當事人的影響，而是案件對社會經濟生活的影響。法官在權衡後果以後，根據後果再去尋找合適法條，然後再運用法律解釋技術加以正當化論證。換句話說，法官在分析案件時有兩個步驟：第一是發現，第二是證成。發現是後果導向的，需要社科法學的分析，而證成則是法教義學的工作¹⁸。

當然，有人會反問，法教義學難道不考慮後果嗎？的確，對於常規案件，選擇法條和考慮後果其實已經同步，如果不涉及疑難案件，並不需要專門考慮後果。正如法教義學所宣稱的，教義的主要功能是簡化論證。如果先考慮後果，再考慮選擇什麼法條，這已經與法教義學基本原則相背離。而社科法學將後果視為最徹底的判斷，顯然是承繼了美國法律現實主義傳統，「現實主義的遺產在法律實踐和法律教育方面的表現為：律師現在承認法官所受到的影響不僅僅是法律規則而已；法官和律師公開考慮法律規則和判決的政

張五常，經濟解釋卷四：制度的選擇，頁1以下（2014年）。

¹⁸ 例如，許霆案的疑難之處，就在於根據後果，找不到合適的法條。否則，也不會引發這麼多爭議。一旦在不確定狀態下，法官或學者認定依據某一個法條之後，餘下的工作只不過是最大化的正當化說理。相關討論可參見2009年《中外法學》第1期的許霆案專題。參見陳興良，利用櫃員機故障惡意取款行為之定性研究，中外法學，2009年第1期，頁6-29（2009年）；張明楷，許霆案的刑法學分析，中外法學，2009年第1期，頁30-56（2009年）；劉明祥，許霆案的定性：盜竊還是信用卡詐騙，中外法學，2009年第1期，頁57-66（2009年）；陳瑞華，脫韁的野馬——從許霆案看法院的自由裁量權，中外法學，2009年第1期，頁67-81（2009年）；周安平，許霆案的民意：按照大數法則的分析，中外法學，2009年第1期，頁82-92（2009年）；蘇力，法條主義、民意與難辦案件，中外法學，2009年第1期，頁93-111（2009年）。

策和政治後果。法律文本現在常常考慮司法判決所處的政治、經濟和歷史語境。¹⁹」

社科法學不同的研究進路，對於後果的考慮會有所不同。例如，法律經濟學注重的是財富或社會福利的最大化，例如，桑本謙的研究；法律社會學注重的是社會結構和秩序的穩定性，例如，朱蘇力的研究；法律人類學注重的是在地人的感受，例如，朱曉陽的研究²⁰。

第三，解釋因果關係。法教義學關心法律問題如何解決，如何用現有的法律規範、法律體系來解決法律問題。但社科法學不太關心是什麼、如何解決，而更關心為什麼、如何解釋的問題。所謂為什麼的問題，就是討論法律問題產生的原因以及所導致的後果。因此可以說，社科法學的核心問題，就是對於因果關係的解釋。

因果關係的問題實際上是一個反事實的問題。就是你在做某一件事情的時候，要反過來想一想，如果你沒有做這一件事情，情形會是什麼樣的²¹？因此，為了簡化問題，就需要引進假設和控制變數。因果關係的解釋，至少可以區別分一果多因和一因多果兩類解釋：一果多因，主要是根據現有的結果，找出造成結果的根本或主要原因。一果多因要比解釋一因多果難得多。例如，列維特（Steven D. Levitt）等人對於1990年代中期美國犯罪率大幅下降與羅伊案關係的解釋²²。一因多果，主要是根據現有現象來預測可能的

19 參見Dennis Patterson編，汪慶華、魏雙娟譯，布萊克維爾法哲學和法律理論指南（2013年）。

20 參見桑本謙，理論法學的迷霧：以轟動案例為素材，頁1以下（2008年）；蘇力，道路通向城市——轉型中國的法治，頁3-44（2004年）；朱曉陽，罪過與懲罰——小村故事：1931—1997，頁1-298（2003年）。

21 謝宇，社會學方法與定量研究，頁44（2006年）。

22 See John J. Donohue III & Steven D. Levitt, *The Impact of Legalized Abortion on Crime*, 116 Q. J. ECON. 379 (2001).

後果。例如，張五常對於勞動合同法對於中國產業影響的分析²³。總體而言，研究原因的結果要比研究結果的原因，更具有可控性和可信度。

社科法學不同的研究進路，對於因果關係的解釋也有所差別。嚴格來說，只有定量研究才能做科學的因果關係的解釋。定量研究注重樣本的代表性，通過提出假設，加以科學驗證。當然，更前沿的研究趨勢是，大資料時代及其資料驅動的計算社會科學研究，會促使研究方式發生革命性的變化²⁴。對於定性研究來說，法律社會學研究可以通過訪談、資料和其他經驗材料獲得因果關係的解釋。而注重田野調查的法律人類學研究，則是在參與觀察，理解他者的過程中，考察事件發生的來龍去脈，但這是比較注重人文的闡釋（interpretation）。例如，吉爾茨（Clifford Geertz）對巴厘人（Balinese）法律意識的研究²⁵。甚至為了更好的闡釋因果關係，也發展出人類學上的延伸個案研究方法²⁶。

第四，「以小見大」的個案研究。社科法學有定性和定量研究之分。在美國，定量研究主要集中在法律經濟學和刑事司法領域。而在中國，近年來也出現了一些定量研究。定量研究除了有為數不多獨立完成的研究以外²⁷，也出現了法學與外學科學者的合作研

23 張五常，張五常論新勞動法，法律和社會科學，2009年第4卷，頁1-36（2009年）。

24 See David Lazer et al., *Life in the Network: The Coming Age of Computational Social Science*, 323 (5915) Sci. 721, 721-23 (2009).

25 參見Clifford Geertz著，王海龍、張家瑄譯，地方性知識——闡釋人類學論文集，頁232-296（2000年）。

26 See Michael Burawoy, *The Extended Case Method*, 16 SOC. THEORY 4 (1998).

27 例如，張永健，訴願制度運作成效之實證評估架構——以臺灣內政部2006-2009年訴願案件為例，北大法律評論，2013年第2輯，頁344-388（2013年）；參見張巍，「海龜」比「土龍」跑得更快嗎？——針對中國一流法學院師資學術表現的一個計量研究，光華法學，2009年第4輯（2009年）；白建軍，從中國犯罪率資料看罪因、罪行與刑罰的關係，中國社會科學，2010年第2期，頁144-159（2010年）；程金華，法律人從政：合理性分析及其驗證，中外法學，2013年第1期，頁114-132（2013年）。

究，例如，唐應茂與經濟學者盛柳剛，賀欣與社會學者蘇陽²⁸。但整體來說，國內的社科法學界，不論是法律經濟學、法律社會學、法律人類學，還是以個案的經驗研究見長。

既然是個案研究，少不了要被批評所謂的個案代表性的問題。但是否具有代表性，向來是評判定量而不是定性研究好壞的標準。作為定性研究的個案研究，更重要的意義在於，個案的豐富性和深刻程度。個案研究做的好不好，關鍵看，這樣的個案研究能否做到以小見大，能否通過個案展現出理論的解釋力，甚至加以理論化。

但問題是，既然個案研究沒有代表性，又怎麼可能「以小見大」？這是完全可能的。例如，張五常稱讚科斯最出色的研究，是關於聯邦通訊委員會的個案，這一研究為其隨後寫作《社會成本問題》奠定基礎²⁹。而張五常自己的研究也是以個案見長³⁰。此外，像埃裡克森（Erik Homburger Erikson）對夏斯塔縣（Shasta）牲畜越界的研究、波斯納（Richard A. Posner）對古希臘初民社會的研究³¹，都是典型的以小見大的個案研究。埃裡克森在書的第1頁還專門寫道：「世界偏僻角落發生的事件可以說明有關社會生活組織的中心問題」³²。

說到底，研究只有好壞之分，好的研究首先需要的是，具有敏銳的觀察力和想像力³³。這需要知識積累、經驗積累，甚至取決於

28 參見，唐應茂、盛柳剛，民商事執行程式中的「雙高現象」，法律與社會科學，2006年第1卷，頁1-29（2006年）；see Xin He & Yang Su, *Do the "Haves" Come Out Ahead in Shanghai Courts?*, 10(1) J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 121, 121-46 (2013).

29 Ronald H. Coase, *The Federal Communications Commission*, 2 J.L. ECON. 1, 1-40 (1959).

30 參見張五常，新賣桔者言，頁1以下（2010年）。

31 參見Richard A. Posner著，蘇力譯，正義／司法的經濟學，頁119-238（2002年）。

32 Robert C. Ellickson著，蘇力譯，無需法律的秩序，頁1（2003年）。

33 參見蘇力（註13），頁16-20。

個人天賦。其次才是解釋力，即是考慮如何論證或驗證，是通過定性還是定量。當然，定量研究和定性研究相結合，更容易生產出好的研究，因此，這也是社科法學未來發展的趨勢。

第五，語境論。社科法學看起來似乎特別重視方法，重視問題的討論。但方法的運用、所有問題的討論，都必須嵌入在中國實際中才有意義。這類似於格蘭諾維特（Mark Granovetter）鑲嵌理論所強調的，經濟行動鑲嵌於社會結構和社會關係之中³⁴，也就是人類學家莫斯（Marcel Mauss）所說的「總體的社會事實」³⁵。因此，法律問題的討論，也必須嵌入到具體的社會經濟文化傳統中才有意義。說到底，所謂語境，就是具體的制度約束，或是張五常所稱的「約束條件」。例如，在中國的法律經濟學研究中，就是反對科斯（Ronald H. Coase）所批評的黑板經濟學、甚至反對理性人假設³⁶。當然，美國法律經濟學的發展，也轉向了強調認知心理的行為法律經濟學、實驗法律經濟學。而在中國的法律社會學研究，與經濟社會學、組織社會學在知識上也有很強的聯繫。

在研究進路上，儘管社科法學源於西方特別是美國的知識傳統，但不論是在概念使用、知識運用，還是分析思路上，也都會強調在中國語境下加以檢驗。研究需要在理論與經驗之間來回往復的不斷理解。一個好的社科法學研究，是可以通過對中國問題的研究，修正和挑戰既有理論，而不是要為西方主流理論提供又一個中國的例證或例外³⁷，從而建設中國社科法學的新傳統。

34 參見Mark Granovetter著，羅家德譯，鑲嵌：社會網與經濟行動，頁1-37（2007年）。

35 Marcel Mauss著，汲喆譯，禮物：古式社會交換中的形式與理由，頁176（2005年）。

36 波斯納也認為法律經濟學並不能適用於中國司法。參見Richard A. Posner著，陳銘宇譯，法律經濟學與法律實用主義，北大法律評論，2013年第1輯，頁4-12（2013年）。

37 馮象，法學院往何處去，清華法學，2004年第1期，頁288-296（2004年）。

肆、「社科法學」的功用

雖然社科法學已經生產不少知識產品，甚至在一定程度上擺脫了，成凡在2005年所形容「社會科學包裝法學」的趕時髦階段³⁸。但是，不少人對社科法學的功用仍有很大懷疑：為什麼要在法學院從事社會科學的研究，這豈不是不務正業？首先你得承認，即使都是法學專業訓練，但研究者的偏好仍會有很大不同。其次，社科法學與法教義學、政法法學相比，仍有一些不可替代的功用：

一、填補法學和其他社會科學的空隙

有人會批評，那些在法學院從事社科法學的研究者，並沒有多少人受到過嚴格的社會科學訓練。研究怎麼可信？！從現有研究群體的結構來看，只有少數是從法學院本科畢業，最後獲得法學之外的博士；有一部分是從法學院博士畢業，選擇法學之外的博士後工作兩年，再回到法學院任教；還有一部分沒有獲得過法學之外的學位，主要是通過自學或有知識偏愛而從事社科法學研究，俗稱「野路子」。這與美國頂尖法學院的師資結構有很大不同³⁹。但就目前來說，重要的不是教育背景，而是做出來的東西。社科法學已經生產出越來越多的好的知識產品，不但有可讀性，而且還有市場競爭力。更何況，社科法學者的群體結構已經發生改變。

社科法學是在法學院從事社會科學的研究。除了有法理專業出身的學者以外，也有越來越多的部門法學者從事社科法學研究，特別是經濟法、訴訟法。一般來說，社科法學區別於以法條為核心的傳統法學研究，同時，與在外院所從事法律研究（他們大多受到嚴

38 成凡，社會科學「包裝」法學？——它的社會科學含義，北大法律評論，2005年第1輯，頁92-114（2005年）。

39 目前在全美排名前13的一流法學院中，有1/3教員、排名前14到26的法學院有1/5教員，具有法學以外的博士學位。See Joni Hersch & W. Kip Viscusi, *Law and Economics as a Pillar of Legal Education*, 8(2) REV. L. & ECON. 487 (2012).

格的社會科學訓練）也有較大差異。似乎是夾在兩者之間，容易被雙方都不待見。但社科法學的存在，恰恰是填補了法學與其他社會科學之間的知識空隙，成為連接法學和其他社會科學的中間地帶。例如，外院所從事法律研究的社科法學者，往往缺乏有效資訊，容易對法律條文、法律理論的理解存在偏差，社科法學者可以彌補這一缺陷。而法條研究者由於知識選擇的有限性，有時也需要社科法學者提供必要的、能夠為法條研究者所理解的外學科知識。

因此，社科法學的比較優勢，就在於可以做跨界對話的工作，促進知識的交流、競爭與合作。除了在社科法學內部，以年會的形式組織法律經濟學、法律社會學、法律人類學、法律與認知科學之間的跨界對話之外，還可以組織法學與外學科的對話，例如，在2006年組織的「法學與人類學對話會」⁴⁰，以及與法教義學的對話⁴¹。

二、通過經驗研究形成中國法律理論

經驗研究是社科法學與法教義學、政法法學的重要區別。儘管後者有時也會宣稱做經驗，對經驗的理解其實不同。政法法學的經驗可能是政治判斷和政治理論的梳理，法教義學的經驗可能是對法律規範和判例技術的整理。而社科法學所強調的經驗研究，是對社會事實的把握。社會科學的使命首先是呈現社會事實，然後以此為據建立理解社會的角度，建立進入「社會」範疇的思想方式，並在這個過程之中不斷磨礪有效呈現社會事實並對其加以解釋的方法⁴²。而人們對法律問題的判斷，對法律現象的看法，其背後往往

40 這次會議由北京大學社會學系、法學院和《中國社會科學》編輯部主辦。會議綜述參見朱曉陽、侯猛編，法律與人類學：中國讀本，頁395-410（2008年）。

41 2014年5月31日至6月1日，在中南財經政法大學法學院舉辦的「社科法學與法教義學的對話」。

42 參見高丙中，中國社會科學需要培育紮實的民族志基本功，民間文化論壇，2006年第2期，頁106-108（2006年）。

存在經驗基礎⁴³。因此，為了創造中國的法律理論，而不是在中國的（西方）法律理論，必須要用中國經驗研究特別是民族志研究作為基石。既關注整體，也關注細節，全部細節。

當然，有人會從事實和規範兩分出發進行質疑：從經驗到理論，怎麼可能實現驚險的一躍？這可能就是認識論的差別。從經驗到理論，主要還是基於歸納和提煉。

還需要區分的是，「實證」和「經驗」的概念使用問題。在社科法學中，實證研究和經驗研究是一樣的意思，都是empirical research。但在注釋法學或法教義學看來，實證是指法律實證主義、實證法（positive law），以與自然法相區別。為了避免語言混亂，社科法學儘量用「經驗研究」一詞，將實證局限於實證法含義的使用。

三、解決法教義學不能解決的問題

社科法學雖然源自美國傳統，但面臨的問題卻有很大不同。美國是判例法國家，判例法研究與社科法學同源，社會科學研究可以與判例法很好的結合。但中國是制定法傳統，案例的分析，基本上還是被與制定法傳統密切聯繫的法教義學所壟斷。社科法學的介入，首當其衝要接受來自法教義學的挑戰。但法教義學也有短板，這讓社科法學有了可能發揮作用的空間。

法教義學存在的前提，是要有一個相對穩定的法秩序。而處於轉型之中的當代中國，法秩序還沒有得以穩定建立。因為穩定的法秩序不彰，中國的法教義學知識體系實際上還沒有建立起來。而社科法學則可以解釋法律與社會之間的張力，考察變動法律秩序的問題，從而發現建設中國法治面臨的具體問題。因此，社科法學也並

43 參見陳柏峰，法律實證研究中的「經驗」，法學，2013年第4期，頁21-25（2013年）。

非是反法治和解構法治，而是強調法治的複雜性，同樣具有建構法治的作用。在這個意義上也可以說，社科法學與法教義學雙方所在意的，「是如何更好的回應並指引中國的法治實踐。基於不同的學術範式，可能會致力於推進不同的法治實踐。⁴⁴」

法教義學更多是在司法層面解決法律的適用問題。即是考慮如何在尊重法秩序和法體系的前提下，通過最大化解釋法條來解決具體糾紛。但局限在於，法教義學對司法制度本身解釋有限，例如，它很難解釋諸如像美國最高法院為何存在左右之爭的問題。而且，法教義學也比較難對立法和政策產生影響。而社科法學重在解釋因果關係，能夠對法律政策進行評估。因此，社科法學研究能夠成為法律公共政策得以準確制定修改的前提。

即使是在法律適用領域，法教義學也只是在處理常規案件時能夠得以用手。所謂常規案件，就是法教義學類型化的結果：只要再遇到類似案件，就能夠類似處理。但是，法教義學難以處理疑難案件⁴⁵，更準確的說，法教義學在處理重大案件時，可能難以發揮作用。所謂重大案件，是指案件除了對當事人產生影響之外，還會對社會經濟生活產生更為廣泛的影響。如何分析這些影響，正是社科法學的用武之地。社科法學通過後果分析，來展現出對法律問題的解釋力和說服力，以及知識競爭力。

四、職業訓練、智識挑戰與政治判斷

法教義學對於法學院的常規職業訓練仍然有用。學生在分析一般性的具體案例時，必須借助於法教義學的這套形式推理的思維技

44 參見李晟，實踐視角下的社科法學：以法教義學為對照，法商研究，2014年第5期，頁81-86（2014年）。

45 參見蘇力，法律人思維？，北大法律評論，2013年第2輯，頁429-469（2013年）；桑本謙，「法律人思維」是怎樣形成的——一個生態競爭的視角，法律和社會科學，2014年第1期，頁1-15（2014年）。

術。對於學生來說，法教義學或許未必有趣但有用。而社科法學則是有趣但卻難有用武之地。法教義學之所以有用，是因為它在刑法、民法這樣的基本法律部門中已經建構了強的知識傳統。並且可以舉一反三，推廣至其他部門法的運用中。但是，除了民法、刑法以及憲法，其他部門法包括訴訟法、行政法、經濟法，可能還難以教義化。來自金融法的學者繆因知就提到，在法教義學和社科法學理論高峰下，存在諸如金融法這樣的「平原」區域，學者們也不得不或饒有興趣地開始學習，在二峰目光的審視下看待自己⁴⁶。

從這個意義上來看，社科法學在職業訓練方面也不是無所作為。它的比較優勢就是跨學科知識偏好。它的存在價值，就在於給法學人提出智識上的挑戰。對於研究者來說，重要的是發現知識的有趣程度。但這並不是說，社科法學只是自娛自樂，走向知識化和科學化。實際上，社科法學最終還是要走向世俗化。因為社科法學對於處理轉型問題和重大案件有解釋力，因此，應當通過知識生產來增強這種解釋力。

社科法學對於政治意識形態的理解，與法教義學、政法法學也有所不同。法教義學試圖將政治問題技術化，從而區隔政治問題和法律問題。例如，「在既有的成文憲法之下，將各種利益紛爭和意識形態對立限定於規範的場域，將各種價值爭議盡可能技術化為法律的規範性爭議，是構築社會的重疊共識並最終走向憲法政治的不二法門。⁴⁷」而政法法學則將所有法律問題在本質上歸結於政治問題，同時外在表徵為宏大理論的敘事⁴⁸。社科法學大致反對宏大敘

46 參見繆因知，社科法學與法教義學兩峰下的平原：來自金融法的視角，「社科法學與法教義學的對話」學術研討會，中南財經政法大學法學院、法學研究、法律和社會科學、社科法學主辦（2014年5月31日、6月1日）。

47 參見張翔（註2）。

48 例如，強世功的研究。參見強世功，立法者的法理學，頁1以下（2007年）；強世功，中國憲法中的不成文憲法——理解中國憲法的新視角，開放時代，2009年第12期，頁10-39（2009年）。

事，而注重經驗研究。但由於後果判斷有時就包括政治判斷，社科法學不可避免要加以因果關係的解釋。總體上來看，社科法學對於知識和學術是採取實用和中立的態度的。

參考文獻

1. 中文部分

- Clifford Geertz著，王海龍、張家瑄譯（2000），地方性知識——闡釋人類學論文集，北京：中央編輯出版社。[Geertz, Clifford. 1985. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York, NY: Basic Books.]
- Dennis Patterson編，汪慶華、魏雙娟譯（2013），布萊克維爾法哲學和法律理論指南，上海：上海人民出版社。[Patterson, Dennis, ed. 1999. *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. New Jersey, NJ: Wiley-Blackwell.]
- Karl Larenz著，陳愛娥譯（2003），《法學方法論》導讀——代譯序，收於：許顯明編，法學方法論，頁2-18，北京：商務印書館。[Larenz, Karl (1999), *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Berlin: Springer.]
- Ludwig Wittgenstein著，李步樓譯（2000），哲學研究，北京：商務印書館。[Wittgenstein, Ludwig (1984), *Philosophische Untersuchungen*, Berlin: Suhrkamp Verlag.]
- Marcel Mauss著，汲喆譯（2005），禮物：古式社會交換中的形式與理由，上海：上海世紀出版集團。[Mauss, Marcel (1925), *Essai sur le don: Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, Paris: Presses Universitaires de France.]
- Mark Yranooetter著，羅家德譯（2007），鑲嵌：社會網與經濟行動，北京：社會科學文獻出版社。[Yranooetter, Mark. 2007. *Embeddedness: Social Network and Economic Action*. Beijing: Social Sciences Academic Press.]

- Niklas Luhmann著，鄭伊倩譯（2009），社會的法律，北京：人民出版社。[Luhmann, Niklas (1995), *Das Recht der Gesellschaft*, Berlin: Suhrkamp Verlag.]
- Richard A. Posner著，陳銘宇譯（2013），法律經濟學與法律實用主義，北大法律評論，2013年第1輯，頁4-12。[Posner, Richard A. 2012. Keynote Speech: Economic Analysis of Law and Legal Pragmatism, July 12, 2012. Chicago, IL: Coase-Sandor Institute for Law and Economics, University of Chicago Law School.]
- Richard A. Posner著，蘇力譯（2002），正義／司法的經濟學，北京：中國政法大學出版社。[Posner, Richard A. 1981. *The Economics of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.]
- Robert C. Ellickson著，蘇力譯（2003），無需法律的秩序，北京：中國政法大學出版社。[Ellickson, Robert C. 1994. *Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.]
- Thomas Raiser著，王亞飛譯（2014），法社會學基本問題，北京：法律出版社。
- Thomas S. Kuhn著，金吾倫、胡新和譯（2013），科學革命的結構，北京：北京大學出版社。[Kuhn, Thomas S. 1996. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago, IL: University of Chicago Press.]
- 白建軍（2010），從中國犯罪率資料看罪因、罪行與刑罰的關係，中國社會科學，2010年第2期，頁144-159。
- 白斌（2010），論法教義學：源流、特徵及其功能，環球法律評論，2010年第3期，頁5-17。
- 成凡（2005），社會科學「包裝」法學？——它的社會科學含義，北大法律評論，2005年第1輯，頁92-114。
- 朱曉陽（2003），罪過與懲罰——小村故事：1931—1997，天津：天津古籍出版社。

- 朱曉陽、侯猛編（2008），法律與人類學：中國讀本，北京：北京大學出版社。
- 李忠夏（2014），基本權利教義學中的價值判斷——基於社科法學與法教義學的視角，「社科法學與法教義學的對話」學術研討會，中南財經政法大學法學院、法學研究、法律和社會科學、社科法學主辦，2014年5月31日、6月1日。
- 李晟（2014），實踐視角下的社科法學：以法教義學為對照，法商研究，2014年第5期，頁81-86。
- 李學堯、王淩皞（2012年），法律與科學的關係：尋求一種開放的法學立場，中國社會科學報，2012年11月14日A07版。
- 周安平（2009），許霆案的民意：按照大數法則的分析，中外法學，2009年第1期，頁82-92。
- 侯猛（2013），社科法學的跨界格局與實證前景，法學，2013年第4期，頁30-35。
- 唐應茂、盛柳剛（2006），民商事執行程式中的「雙高現象」，法律和社會科學，2006年第1卷，頁1-29。
- 桑本謙（2008），理論法學的迷霧：以轟動案例為素材，北京：法律出版社。
- （2014），「法律人思維」是怎樣形成的——一個生態競爭的視角，法律和社會科學，2014年第1期，頁1-25。
- 高丙中（2006），中國社會科學需要培育扎實的民族志基本功，民間文化論壇，2006年第2期，頁106-108。
- 張五常（2009），張五常論新勞動法，法律和社會科學，2009年第4卷，頁1-36。
- （2010），新賣桔者言，北京：中信出版社。
- （2014），經濟解釋卷四：制度的選擇，北京：中信出版社。
- 張永健（2013），訴願制度運作成效之實證評估架構——以臺灣內政部2006-2009年訴願案件為例，北大法律評論，2013年

第2輯，頁344-388。

張明楷（2009），許霆案的刑法學分析，中外法學，2009年第1期，頁30-56。

張翔（2013），憲法教義學初階，中外法學，2013年第5期，頁916-936。

張巍（2009），「海龜」比「土鼈」跑得更快嗎？——針對中國一流法學院師資學術表現的一個計量研究，光華法學，2009年第4輯，頁13-28。

強世功（2007），立法者的法理學，香港：三聯書店。

——（2009），中國憲法中的不成文憲法——理解中國憲法的新視角，開放時代，2009年第12期，頁10-39。

——（2013），中國法律社會學的困境與出路，文化縱橫，2013年第5期，頁114-120。

許德風（2008），論法教義學與價值判斷——以民法方法為重點，中外法學，2008年第2期，頁165-190。

——（2013），法教義學的應用，中外法學，2013年第5期，頁937-973。

陳柏峰（2013），法律實證研究中的「經驗」，法學，2013年第4期，頁21-25。

陳瑞華（2009），脫韁的野馬——從許霆案看法院的自由裁量權，中外法學，2009年第1期，頁67-81。

陳興良（2005），刑法教義學方法論，法學研究，2005年第2期，頁38-56。

——（2009），利用櫃員機故障惡意取款行為之定性研究，中外法學，2009年第1期，頁6-29。

焦寶乾（2006年），法教義學的觀念及其演變，法商研究，2006年第4期，頁88-93。

程金華（2013），法律人從政：合理性分析及其驗證，中外法學，2013年第1期，頁114-132。

- 賀欣（2006），轉型中國背景下的法律和社會科學研究，北大法律評論，2006年第1輯，頁21-36。
- 馮象（2004），法學院往何處去，清華法學，2004年第1期，頁288-296。
- 趙旭東（2011），法律與文化：法律人類學研究與中國經驗，北京：北京大學出版社。
- 劉明祥（2009），許霆案的定性：盜竊還是信用卡詐騙，中外法學，2009年第1期，頁57-66。
- 劉思達（2010），中國法律社會學的歷史與反思，法律和社會科學，2010年第2期，頁25-37。
- 鄭戈（1998），法學是一門社會科學嗎？——試論「法律科學」的屬性及其研究方法，北大法律評論，1998年第1輯，頁13-42。
- 繆因知（2014），社科法學與法教義學兩峰下的平原：來自金融法的視角，「社科法學與法教義學的對話」學術研討會，中南財經政法大學法學院、法學研究、法律和社會科學、社科法學主辦，2014年5月31日、6月1日。
- 謝宇（2006），社會學方法與定量研究，北京：社會科學文獻出版社。
- 蘇力（2001），也許正在發生——中國當代法學發展的一個概覽，比較法研究，2001年第3期，頁1-9。
- （2004），道路通向城市——轉型中國的法治，北京：法律出版社。
- （2013），好的研究和實證研究，法學，2013年第4期，頁16-20。
- （2013），法律人思維？，北大法律評論，2013年第2輯，頁429-469。
- （2009），法條主義、民意與難辦案件，中外法學，2009年第1期，頁93-111。

2. 外文部分

- Burawoy, Michael. 1998. The Extended Case Method. *Sociological Theory* 16:4-33.
- Coase, Ronald H. 1959. The Federal Communications Commission. *The Journal of Law and Economics* 2:1-40.
- Donohue III, John J., and Steven D. Levitt. 2001. The Impact of Legalized Abortion on Crime. *The Quarterly Journal of Economics* 116:379-420.
- He, Xin. 2012. Black Hole of Responsibility: The Adjudication Committee's Role in a Chinese Court. *Law & Society Review* 46:681-712.
- He, Xin, and Yang Su. 2013. Do the "Haves" Come Out Ahead in Shanghai Courts?. *Journal of Empirical Legal Studies* 10(1):121-146.
- Hersch, Joni, and W. Kip Viscusi. 2012. Law and Economics as a Pillar of Legal Education. *Review of Law & Economics* 8(2):487-510.
- Lazer, David, Alex (Sandy) Pentland, Lada Adamic, Sinan Aral, Albert Laszlo Barabasi, Devon Brewer, Nicholas Christakis, Noshir Contractor, James Fowler, Myron Gutmann, Tony Jebara, Gary King, Michael Macy, Deb Roy, and Marshall Van Alstyne. 2009. Life in the Network: The Coming Age of Computational Social Science. *Science* 323 (5915):721-723.

The Tradition and Challenge of Law and Social Sciences

*Meng Hou**

Abstract

The field of law and social sciences of China was formed by collaborative research work and research groups. This means that it is not sociology of law in the traditional sense, nor does it use a new concept to refer to interdisciplinary legal research. It is special because a multilateral, cross-border dialogue mechanism has been established to integrate interdisciplinary legal research based on different approaches. In the course of continuous dialogue, the scholars of law and social sciences, with their different approaches, have formed a basic consensus for empirical research, pragmatism, a consequence-driven orientation, and contextual analysis. But on the whole, law and social sciences must strengthen the identification of its knowledge tradition through competition with legal dogmatics.

KEYWORDS: empirical research, pragmatism, consequence orientation, contextual analysis.

* Associate Professor, Peking University Law School.

